

1500286-75.2021.8.26.0580

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Comarca: Cândido Mota

Foro: Foro de Cândido Mota

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... de que eles estariam praticando tráfico de drogas. Na ocasião o depoente estava no comando da equipe. Na ocasião, existiam fundadas razões pela ocorrência do tráfico de drogas, havia farta quantidade de drogas com o irmão de Fábio em situação anterior, também a informação de que Fábio deu em relação às drogas, isso levou a equipe a buscar a autorização de Fábio, foi feita a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cândido Mota

Foro de Cândido Mota

1ª Vara

Praça Antonio Pípolo,s/nº, Candido Mota-SP - cep 19880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500286-75.2021.8.26.0580 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500286-75.2021.8.26.0580

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199739/2021 - DEL.POL.CÂNDIDO MOTA, 19216599 - DEL.POL.CÂNDIDO MOTA, 673/21/104 - DEL.POL.CÂNDIDO MOTA, 2199739 - DEL.POL.CÂNDIDO MOTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO AUGUSTO BRAZ DE AQUINO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de MARCOS ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA e FABIO AUGUSTO BRAZ DE AQUINO, ambos qualificados nos autos, como incurso nas condutas previstas no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006. Segundo a denúncia, em data de 24 de julho de 2021, por volta das 1h50min, na Avenida Gilfredo Boreti, n.º 462, nesta cidade e comarca de Cândido Mota, os acusados com unidade de desígnios e propósitos, um aderindo à conduta ilícita do outro, teriam trazido consigo e guardavam drogas que seriam destinadas à

entrega para terceiros, consistentes em 85 (oitenta e cinco) porções de maconha, com massa líquida de 146,88g, já divididas e prontas para o comércio e 03 (três) porções maiores da mesma droga, com massa líquida total de 607,56 g, ainda não fracionadas, todas destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva às fls. 84/88.

Recebida a denúncia (fls. 222/225), os réus foram citados (fls. 194 e fls. 196) e apresentaram defesa prévia (fls. 185/189 e 212/216).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa e, ao final, realizado o interrogatório do denunciado.

Em sede de alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, nos exatos termos da exordial. As defesas, por sua vez, após tecerem considerações quanto às provas produzidas, pugnaram pela absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, observo que a defesa de Fábio Augusto aduz duas preliminares, as quais passo à análise.

No que atine à preliminar de nulidade por não apreciação da impugnação da defesa quanto ao laudo pericial, entendo que não assiste razão à defesa. Com efeito, o laudo pericial de fls. 357/359 foi realizado por instituto oficial de criminalística, inexistindo quaisquer elementos nos autos, tampouco da impugnação anterior pela defesa, que possa desmerecer ou desacreditar o trabalho realizado pelo expert. Nessa toada, a conclusão do laudo pericial de fls. 357/359, bem como sua fundamentação são suficientes a fim de se aferir que, de fato, seria de punho do acusado a assinatura constante da autorização de entrada em domicílio.

Consigno, ainda, que como se verá em sequência, a autorização escrita sequer será utilizada para fins de fundamentação quanto ao ingresso dos policiais em domicílio, de forma, portanto, que mesmo que a perícia concluísse a ausência de assinatura por parte do réu, a conclusão da presente sentença não seria diversa. Dessa forma, aplica-se, também, o princípio da instrumentalidade das formas.

Em sequência, no que se refere à preliminar quanto à nulidade decorrente de eventual ingresso ilícito dos policiais no domicílio do acusado, consigno que, também não assiste razão à defesa.

Com efeito, a legalidade do flagrante já havia sido analisada quando da conversão da prisão em preventiva. Sem prejuízo, tratando-se de matéria de ordem pública, nada obsta que a defesa realize, posteriormente, novos requerimentos para serem analisados.

Nessa toada, entendo que no caso em tela existiam fundadas razões para que os policiais, independentemente de autorização escrita dos denunciados, realizassem o ingresso no domicílio dos réus. Tal ponto, por si só, também afasta o pedido de nulidade da perícia, notadamente porque a referida autorização de ingresso, seja de punho do réu ou não, não será utilizada para fins de fundamentação da licitude de ingresso em domicílio.

Assim, depreende-se dos autos que, na data dos fatos, os acusados, que estariam em via pública, tendo sido encontrado, em um primeiro momento, considerável quantidade de entorpecentes - "maconha" - com o acusado Marcos. Embora, de fato, com Fábio não tenha sido, em um primeiro momento, encontrado nada de ilícito, certo é que, pela versão dada pelos policiais, os acusados, que estavam juntos, teriam relatado que estariam realizando a traficância, bem como que a parte restante dos entorpecentes estaria na residência de Fábio.

Diante de tal cenário, certo é que, com as informações existentes naquele momento, os policiais militares tinham, de fato, fundadas razões a fim de se aferir que, na residência de Fábio, ocorria o depósito de entorpecentes para traficância e, sendo este um delito de natureza permanente, passível de ocorrer o ingresso para fins de flagrante.

A esse respeito, já se manifestou o Excelso Pretório:

"[...] 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre

situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento de recurso. (STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015).

In casu, policiais abordaram o réu em via pública e com ele foram encontradas droga e quantia em dinheiro.

No julgamento do mencionado RE 603.616, o STF reconheceu a licitude da apreensão de droga encontrada no interior de um veículo, estacionado na garagem do recorrente, sem mandado judicial. Segundo consta do voto, a Polícia já mantinha informações que o recorrente promovia o tráfico de drogas com terceira pessoa. Esta foi abordada e presa quando transportava drogas, quando indicou que recebera drogas do recorrente. Os policiais dirigiram-se à casa deste e lograram encontrar a droga dentro do indicado veículo, estacionado na garagem.

Ora, trata-se de situação que muito se assemelha à presente. Os policiais não foram ao local com base unicamente em denúncias anônimas ou meros critérios subjetivos, mas sim após encontrarem, com os acusados, entorpecentes sendo transportados em via pública, bem como com a informação dada pelos acusados de que teriam mais entorpecentes na residência. Não haveria outra conduta a ser tomada, naquele momento, que não a diligência efetuada pelos policiais.

Consigno, assim, que a situação de reconhecida higidez constitucional pelo STF não diverge, na essência, do caso vertente. Seria diferente se, apenas com base em informação anônima, os policiais tivessem promovido a entrada forçada, sem apreensão anterior de drogas, ou visualização de condutas, defronte a residência, que pudessem indicar o tráfico.⁴ Na hipótese presente, pelo contrário, os elementos indicados são suficientes à indicação da justa causa e à reafirmação da higidez da atuação policial.

Por fim, não se desconhece a decisão da 6ª Turma do STJ, nos autos de HC 598051/SP, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, datado de 02/03/2021. O entendimento da Corte no referido julgamento, todavia, não macula ou de qualquer maneira dá margem à interpretação de que a prova produzida neste feito seja ilícita. Isto porque, conforme exposto acima, havia fundadas razões para o ingresso na residência, o qual, inclusive, foi autorizado. Além disso, O Min. Relator propôs e a 6ª Turma concordou com a fixação do prazo de 1 (um) ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da decisão.

Afastadas as preliminares, inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para saneamento, passo à análise do mérito.

Dessa forma, primeiramente, cumpre ressaltar que vige em nosso ordenamento jurídico o sistema acusatório, no qual estão delineadas as funções de acusar, defender e julgar, o que, por consentâneo, traduz-se durante a persecução penal uma distribuição lógica do ônus da prova, de acordo com os interesses imperativos de cada parte.

Na esteira da melhor doutrina, caberá à acusação provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras. Conquanto à defesa, a prova de eventuais causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de tipicidade, circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena que tenha alegado.

No que se refere aos efeitos da produção da prova, direcionados ao magistrado, caberá ao Ministério Público a produção de provas que concretizem um juízo de certeza, enquanto à defesa, basta a produção de um cenário de dúvida ao julgador. Nesse sentido:

"Em suma, enquanto o Ministério Público e o querelante têm o ônus de provar os fatos delituosos além de qualquer dúvida razoável, produzindo no magistrado um juízo de certeza em relação ao fato delituoso imputado ao acusado, à defesa é suficiente gerar apenas uma fundada dúvida sobre causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, causas extintivas da punibilidade ou acerca de

eventual álibi. Há, inegavelmente, uma distinção em relação ao quantum de prova necessário para cumprir o ônus da prova: para a acusação, exige-se prova além de qualquer dúvida razoável; para a defesa, basta criar um estado de dúvida. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 574.)"

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 19/22), auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, laudo toxicológico definitivo (fls. 244/246), bem como pela prova oral colhida em juízo. A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre os denunciados.

Vejamos as provas orais colhidas em juízo.

Ouvida em juízo a testemunha Luciano Da Rocha Maciel, policial militar, relatou que na data dos fatos estavam em patrulhamento em Cândido Mota. Se depararam com duas pessoas em atitude suspeita. Foram abordados próximos à empresa Conti. Com Marcos foi encontrada certa quantia de Maconha, celular e dinheiro. Com Fábio um celular. Entrevistaram ambos no local. Tomaram conhecimento de que eles estariam ali para comercializar drogas, associados os dois. O Marcos informou que havia saído há pouco tempo da cadeia e estava nessa transação de drogas. O Fábio informou que tinha droga na residência, levou a equipe até lá e mostrou no fundo do quintal, de baixo de uma madeira, uma quantidade de drogas, entregando essa droga ao depoente. Foram até o quarto dele em uma cômoda, tinha faca, balança. Com todas essas informações tiveram a certeza de que eles estariam praticando tráfico de drogas. Na ocasião o depoente estava no comando da equipe. Na ocasião, existiam fundadas razões pela ocorrência do tráfico de drogas, havia farta quantidade de drogas com o irmão de Fábio em situação anterior, também a informação de que Fábio deu em relação às drogas, isso levou a equipe a buscar a autorização de Fábio, foi feita a autorização, e então adentraram na residência. Essa autorização fica arquivada nos relatórios de serviços operacionais da Polícia Militar. No local existiam outras pessoas, a princípio estavam em festa no cômodo da frente, na sala. Foram todos retirados e abordados. Depois com eles já colocados em segurança, adentrou em outro local à parte da residência com o Fábio, o qual mostrou e entregou a droga. Da forma que estava a droga teria que ficar procurando ou solicitar o canil, como ele entregou a droga não foi chamado. Ele colaborou com a ação. Os apetrechos foram encontrados no quarto do Fábio, atrás de uma cômoda. Ambos não aparentavam estar alterados por álcool ou qualquer outra coisa. Foi feita uma gravação da confissão dos acusados. Estavam em operação, devido ao local e horário, isso motivou a abordagem policial, a atitude deles de visualizar a viatura e tentar tomar outra direção. O Réu Marcos foi encontrado com maconha, não se recorda exatamente a quantidade. As drogas estavam pesadas, foi fracionada uma parte. O Marcos, após pesquisa no sistema, ele também informou que há uma semana havia saído da cadeia por tráfico de drogas. No local ele afirmou que estariam naquela localidade para fazer transação de drogas. O restante da droga foi localizado na residência do Fábio. Não fizeram deslocamento na casa do Marcos. Foram direto para o plantão policial. Já conhecia o Fábio em razão da prisão do irmão Vítor. Dentro da residência tinham pessoas na sala. A droga foi encontrada no fundo do residência, de baixo de uma madeira, entregue pelo Fábio. Não se recorda se há vizinhos do outro lado, acha que é uma parede de uma residência.

Ouvida em juízo a testemunha comum Leonardo Moreno Marques, policial militar, relatou que no dia dos fatos faziam patrulhamento em Cândido Mota, próximo à empresa Conti, quando suspeitaram de dois indivíduos de bicicleta. Com o Marcos Adriano foi encontrada quantidade considerável de maconha. Com o Fábio em primeiro momento não foi localizado nada. Falaram que estariam indo fazer venda a um terceiro e que a propriedade do entorpecente seria dos dois. Na sequência o Fábio confessou que em sua residência havia mais entorpecentes destinada à venda, ocasião na qual ele franqueou a entrada da equipe em sua residência, sendo encontrada mais droga em sua residência, tendo ele indicado a localização da droga. Estavam em três policiais. Eles estavam indo fazer a entrega para outro indivíduo. Foi colhida autorização de entrada na residência e juntada essa autorização no boletim de ocorrência da polícia militar. O depoente ficou fazendo a segurança do lado externo

da residência, ele entrou o entorpecente para o Sargento Maciel. Não se recorda se foi feita gravação de vídeo. Após ser questionado pelo Ministério Público quanto à eventual situação que indicasse estarem sobre efeito de drogas ou álcool, o depoente relatou que aparentavam estar normais. Não os conheciam. Era período noturno e não era local de aparente circulação de pessoas, quando viram a viatura aceleraram a bicicleta e mudaram de direção, razão pela qual realizaram a abordagem. No primeiro momento a droga estava na cintura do Marcos, era um pedaço grande e outros menores. No caso eles narraram que iriam fazer a entrega para outra pessoa. Na hora da abordagem com o Fábio nada foi encontrado, a maconha estava com o Marcos Adriano. Depois narraram que tinha mais entorpecente na residência. Ele falou porque não queria prejudicar quem estaria na residência dele. Na casa dele quando chegaram o pai não se encontrava, mas tinham mais pessoas na casa. Por isso ele já informou que a droga era dele e não queria prejudicar ninguém. Não se recorda quantas pessoas estavam na casa. Não acharam que a droga era das outras pessoas pois o Fábio quem admitiu que o entorpecente era dele e por isso não queria colocar a responsabilidade para ninguém. Ele entregou a droga para o Sargento, ele quem vai poder. Estava cada um em uma bicicleta. Pelas circunstâncias do local era possível afirmar que ambos estavam juntos.

Ouvida em juízo a informante de defesa Thaina Cristina Cardoso Nascimento, relatou que é amiga do Fábio desde o ano passado. O Fábio trabalha de servente com o pai dele. Estava na casa na data dos fatos. Estavam dentro, o Fábio foi buscar a namorada, a menina que ele ficava, depois de uns vinte minutos que ele saiu da casa chegou uma viatura que entrou lá sem mandado e sem autorização, entraram com uma sacola preta e falaram para todos saírem. Depois eles saíram com uma sacola preta, chegou uma viatura da força tática. Depois chegou essa viatura e entraram todos para dentro, a depoente ficou no muro, eles agrediram algumas pessoas. Quando entraram o Fábio não estava junto, não sabia que ele estava na viatura. Estavam sozinhos quando encontraram a droga. Entraram em todos os cômodos da casa. No quarto do Fábio foi encontrado um baseado de maconha, ele é usuário.

Ouvido em juízo o informante de defesa Sérgio Adriano Dos Santos Ferreira relatou que na data dos fatos estava na sala do Fábio. Os policiais entraram e já falaram para saírem todos para fora. De lá não viu mais nada. Eles perguntaram o nome de cada um, onde moravam e liberaram. Quando eles entraram não viu se o Fábio ficou na viatura. Os policiais entraram, mandaram todos saírem, lá dentro o depoente não viu mais nada.

Ouvida em juízo a testemunha de defesa Carlos Eduardo Da Silva Gonçalves relatou que na data dos fatos estava na casa do Fábio quando a polícia chegou. Estavam jogando truco, o Fábio Augusto saiu e depois voltou com os policiais. Entraram dentro da casa e colocaram todos para fora. Estava o irmão dele com os policiais. Ficaram sentados na calçada e viram eles entrando. Lá fora perguntaram o nome de cada um, anotaram. Eles entraram com uma sacola dentro. Eles saíram de lá com essa sacola depois, com a mesma sacola.

Ao final, em seu interrogatório judicial, o denunciado Marcos Adriano Dos Santos Ferreira relatou que na data estava na casa do Fábio em uma festa de aniversário. Na casa dele não tinha droga dentro. Não viram drogas lá. Os policiais que apareceram com as drogas. Estava na rua quando foi abordado. Estava com o Fábio, ele um pouco mais atrás. Tinham marcado de encontrar com duas meninas. Foi abordado em via pública pela polícia. Nenhuma droga foi encontrada com o depoente. Na rua com o Fábio também não tinha droga, nem na casa dele. Não tentaram correr. A polícia derrubou o Fábio no chão, agrediu. Depois desse momento foram na casa do Fábio. Não entrou na residência, primeiro levaram o Fábio. Não entrou na casa do Fábio. Na delegacia que ficou sabendo da droga. Essa droga o depoente não sabia se estava na casa. Não conhecia os policiais. Não viu os demais objetos na residência. Com o depoente não foi encontrada droga em revista pessoal. Não revistaram a casa do depoente. Ficou com o Fábio trancado na viatura. Tinham bebido, estavam na casa deles bebendo. Eles retiraram da delegacia obrigando a assumir a droga.

Ao final, em seu interrogatório judicial, o denunciado Fabio Augusto Braz de Aquino relatou que não são verdadeiras as acusações. Na data estavam fazendo aniversário de um amigo na sua residência. Saiu com o Marcos para encontrar duas meninas

próximo a empresa Conti. A viatura apareceu, abordou ambos. Os policiais apareceram com uma porção de maconha, colocou ambos na viatura e foram para a casa do depoente. O depoente e o Marcos não tinham drogas na rua. Cada um foi colocado em uma viatura. Sabiam onde o depoente morava e foi até lá. Não foi encontrada droga nenhuma na casa do depoente, é mentira. As facas eram da cozinha do depoente, a balança não reconhece. Conhecia só o policial Maciel por ter prendido o irmão do depoente. Depois só viu que entraram na casa do depoente e mostraram a droga. O depoente trabalha com o genitor, tem ensino médio completo. No dia da abordagem tinha trabalho com o pai do depoente, trabalha de segunda a sexta. Faz uso de maconha. No dia não tinha nenhuma droga com o depoente. Não falou espontaneamente nada aos policiais. Não assinou nenhum termo de autorização. O depoente não precisa traficar, pois trabalha com o genitor, tira quatrocentos reais por semana. Pois bem.

A negativa dos acusados restou isolada nos autos.

Com efeito, ambos os policiais militares que atuaram na ocorrência foram uníssonos, tanto em juízo quanto em solo policial, ao afirmar que avistaram ambos os acusados em via pública, durante a madrugada, os quais, ao avistarem a viatura policial, teriam tomado direção diversa, tentando irem em direção diversa da qual os policiais se direcionavam. Em razão de tal situação, realizaram a abordagem e revista pessoal, encontrando inicialmente com o acusado Marcos quantidade de maconha e, também, dinheiro em espécie.

Diante de tal cenário, conforme já fundamentado em sede preliminar, os policiais deslocaram-se à residência de Fábio, o qual estava junto com Marcos na empreitada delituosa, local no qual encontraram grande quantidade de entorpecentes, os quais estão descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, sendo que a somatória das porções de maconha apreendida perfaz a quantia de 607,56g de massa líquida.

Para além da grande quantidade apreendida, também foram encontrados no local apetrechos, tais como balança de precisão e plástico filme, circunstâncias que indicam, nos termos do art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06, que os entorpecentes eram destinados à venda.

De se esclarecer, ainda, que nada há nos autos a indicar que o testemunho dos policiais militares não mereça crédito. Não há provas de que eles queiram deliberadamente prejudicar os acusados, imputando-lhes falsamente a prática de crime.

Não se afigura verossímil, ainda, a versão dos denunciados no sentido de que não traziam consigo em via pública ou, ainda, guardavam em domicílio os entorpecentes apreendidos. Alegam que os policiais teriam "forjado" os entorpecentes para fins de prisão dos denunciados. Crer em tal versão seria, em verdade, indicar que os policiais estariam trazendo consigo mais de meio quilo de drogas em via pública para incriminar terceiras pessoas, versão que, com base no existente nos autos, não merece guarida.

Assim, não há que se acolher quaisquer teses defensivas referente à eventual ausência de provas. Todos os fatos foram cabalmente comprovados.

Provada, assim, a existência material dos crimes imputados, em todos os elementos do tipo pena, bem como a autoria do denunciado, não existindo quaisquer elementos que excluam a ilicitude da conduta ou ainda dirimam a culpabilidade do acusado, é de rigor a condenação.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Em relação ao denunciado Marcos Adriano dos Santos Ferreira:

Na primeira fase da dosimetria, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal em conjunto com o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, o qual dispõe que preponderam neste primeiro momento a natureza e quantidade da substância, a personalidade e conduta social do agente. Pois bem, no que tange ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos revela-se situação negativa a fim de exasperar a pena inicial, vez que foram apreendidas porções de maconha com peso líquido aproximado de 607,56g. Assim, tendo em vista a quantidade relevante apreendida, entendo que tal circunstância se revela negativa, merecedora de maior reprovação. Quanto às

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, consistentes na culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, em geral, são neutras no caso concreto, não havendo o que se valorar. Portanto, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, no patamar de de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho inalterada a pena antes fixada.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento. Verifico que não é caso de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos. A fim de que a referida circunstância seja reconhecida, é necessária a observância de quatro pressupostos de ordem cumulativa, ou seja, o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Pois bem, no caso concreto, em que pese a primariedade do agente, entendo que as circunstâncias em que praticado o tráfico afastam a aplicação da diminuição de pena, pois há sérios indicativos de que o crime em tela não se tratou de evento isolado na vida do denunciado.

Pelo contrário, por todo o contido nos autos, especialmente pela maneira em que o acusado se organizou para a prática da traficância, da quantidade de drogas apreendida, bem como dos apetrechos apreendidos, tais circunstâncias indicam, para além da dúvida razoável, que o agente se dedica às atividades criminosas. Ainda, verifico que o ora denunciado Marcos atualmente responde processo criminal por delito de igual natureza, constante dos autos n. 1500388-34.2020.8.26.0580, circunstância que também indica a atuação do indivíduo em atividades criminosas.

A esse respeito, destaco:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. AÇÕES PENAIIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO REDUTOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Inquéritos policiais e ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base (Súmula n. 444 do STJ), podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 605.968/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)"

Portanto, fixo-lhe a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira do réu.

Em relação ao denunciado Fabio Augusto Braz de Aquino:

Na primeira fase da dosimetria, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal em conjunto com o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, o qual dispõe que preponderam neste primeiro momento a natureza e quantidade da substância, a personalidade e conduta social do agente. Pois bem, no que tange ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos revela-se situação negativa a fim de exasperar a pena inicial, vez que foram apreendidas porções de maconha com peso líquido aproximado de 607,56g. Assim, tendo em vista a quantidade relevante apreendida, entendo que tal circunstância se revela negativa, merecedora de maior reprovação. Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, consistentes na culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, em geral, são neutras no caso concreto, não havendo o que se valorar.

Portanto, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, no patamar de de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho inalterada a pena antes fixada.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento. Verifico que não é caso de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos. A fim de que a referida circunstância seja reconhecida, é necessária a observância de quatro pressupostos de ordem cumulativa, ou seja, o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Pois bem, no caso concreto, em que pese a primariedade do agente, entendo que as circunstâncias em que praticado o tráfico afastam a aplicação da diminuição de pena, pois há sérios indicativos de que o crime em tela não se tratou de evento isolado na vida do denunciado.

Pelo contrário, por todo o contido nos autos, especialmente pela maneira em que o acusado se organizou para a prática da traficância, da quantidade de drogas apreendida, bem como dos apetrechos apreendidos, tais circunstâncias indicam, para além da dúvida razoável, que o agente se dedica às atividades criminosas.

Em situação idêntica referente a feito já julgado por este magistrado, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO - Crime permanente. Prisão em flagrante. Desnecessária a expedição de mandado judicial de busca e apreensão. Condenação baseada em provas lícitas PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – Tendo sido apreendida em poder do réu significativa quantidade de drogas, revelando não se tratar de pequeno e eventual traficante, inviável a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500423-91.2020.8.26.0580; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 27/09/2021)"

Portanto, fixo-lhe a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, em relação à ambos os acusados, será o fechado, a teor do art. 33, §3º do CP.

Isso, pois, embora não se olvide, neste momento, o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado obrigatório para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), com base em controle difuso de constitucionalidade exercido no HC 111.840 e reanalisado no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1052700, de relatoria do ministro Edson Fachin, certo é que, a depender das circunstâncias do caso concreto, verifica-se possível a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que aquele atrelado exclusivamente ao quantum de pena aplicado e disposto no art. 33 do Código Penal.

Assim, quando da fixação do regime inicial, é possível ao magistrado aplicar regime inicial mais gravoso do que aquele atrelado unicamente ao quesito do quantum da pena aplicada, desde que analisadas as circunstâncias do caso concreto, tal como dispõe a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

A esse respeito: Destaco: "A exasperação da pena-base e o respectivo quantum foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. (...) 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante

está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. [HC 145.000 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 17-4-2018, DJE 73 de 17-4-2018.]"

Nessa toada, certo é que, na primeira fase da dosimetria, existiram circunstâncias preponderantes negativas, consistentes na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o que justifica, neste caso, a fixação de regime inicial mais gravoso. No mais, incabível a substituição da pena nos moldes dos artigos 44 e 77 do CP, tendo em vista que condenado à pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal, o que faço para fins de CONDENAR os denunciados MARCOS ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA e AUGUSTO BRAZ DE AQUINO como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, arbitrados no patamar mínimo pecuniário.

Deixo de reconhecer aos réus o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a manutenção de suas prisões cautelares (art. 312 do CPP). Além do que, porque responderam presos ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-los em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória, ficando, desde já, considerada a manutenção da prisão preventiva como fins de revisão processual da prisão, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fulcro no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, cumulado com o art. 63, §1º, da Lei 11.343/06 (redação dada pela Lei 13.840/19).

Caso ainda não tenha sido assim procedido, nos termos do art. 50-A da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Após o trânsito em julgado, suspendam-se os direitos políticos do acusado, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, oficiando-se ao Juízo Eleitoral competente e intime-se o réu para o pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias.

Custas e despesas processuais na forma da lei.

Arbitro honorários ao defensor dativo nomeado pelo convênio entre OAB-DPE/SP no patamar máximo previsto para a respectiva atuação. Expeça-se certidão.

Expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe.

PRIC.

Candido Mota, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA